

1500684-83.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI RUIVO PINHEIRO

Data da Audiência:

25/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500684-83.2020.8.26.0571 - Controle 2020/001021

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI RUIVO PINHEIRO

Data da Audiência:

25/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Davi Ruivo Pinheiro. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Levi Theotônio Filho e Michel Estevan Pontes Antunes arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitativa encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitativa, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos em juízo, os guardas civis responsáveis pela prisão do réu narraram, em tom uníssono, que

realizavam patrulhamento quando notaram o acusado, sendo certo que ao se aproximarem observaram que ele dispensou algo. Realizada a abordagem, com ele apreenderam dinheiro, e ao tomarem o pacote que havia dispensado, nele encontraram as porções de drogas, já divididas em porções individuais, prontas para mercancia clandestina. As palavras dos guardas civis revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do policial; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. O acusado, ao seu turno, a par de admitir a posse dos entorpecentes, aduziu que se destinavam ao próprio consumo. Entretanto, sua versão não há de merecer credibilidade, pois as circunstâncias envolvidas da abordagem, apreensão dos entorpecentes, e, principalmente, a quantidade e forma na qual estava acondicionado revelam, de modo inequívoco, que se destinavam ao comércio espúrio. E vale anotar em arremate, que mesmo admitida a alegada condição de usuário, tal por si só não elide o tráfico; ao contrário, bastante comum nos dias atuais dependentes químicos também se dedicando ao comércio ilícito de entorpecentes até para sustento do vício. Dessa forma, é patente a responsabilidade penal do acusado, que inclusive confessou outrora a responsabilidade pelos fatos quando da realização do ANPP, que restou revogado justamente pelo seu envolvimento noutro crime de tráfico, e pelo qual se encontra preso. Demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, devendo, ademais, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção privativa de liberdade. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, o próprio réu esclareceu que se trata de usuário e que o entorpecente apreendido era para seu uso. Disse que havia acabado de comprar a droga e correu, assustado, quando viu a viatura. Corroborando com o depoimento do réu, a certidão de fls. 132 indica ser ele dependente químico – a sua genitora informou, ao oficial de justiça, que o filho era usuário e que, por isso, sequer parava em casa. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido.

Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse

legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) Na segunda fase de dosimetria da pena deverá ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa; c) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixado regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, ante a primariedade do réu e em conformidade com os arts. 33, 44 e 59 do Código Penal; d) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. DAVI RUIVO PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de maio de 2020, por volta das 20 h e 45 min, na Rua Julia Rodrigues Pinto, n. 29, Vila Belo Horizonte, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, onze porções de “cocaína”, com peso de 7,93 gramas, e duas porções de “maconha”, com peso de 3,07 gramas. O Réu foi notificado por edital, fls. 139, o MP manifestou-se e pediu a prisão preventiva, fls. 144, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar e contrariou o pleito de prisão, fls. 149/151. A denúncia foi recebida, e, na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva, fls. 152/153. O Réu foi citado por edital, fls. 162, e, o cumprimento do mandado de prisão, o Acusado foi citado pessoalmente, fls. 173. Em 02 de março de 2022 foi dado cumprimento à liminar deferida em Habeas Corpus, 193. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação.

É o relatório. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade do delito acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 08/10, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 11/12, no Laudo de Constatação, fls. 16/17, bem como no Exame químico-toxicológico n. 147.620/2020, fls. 72/75, constatando-se a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína. Levi Theotônio Filho e Michel Estevan Pontes Antunes, guardas municipais, testemunhas, disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual, ao ver a viatura, dispensou um invólucro e empreendeu fuga, porém foi abordado e, com ele, houve a apreensão de dinheiro; os guardas recuperaram o invólucro e, dentro dele, havia 11 porções de “cocaína”, com adesivo dos Simpsons, e 02 porções de “maconha”. Em um terreno próximo os guardas encontraram outros 16 tubos plásticos vazios com adesivos dos Simpsons. Davi Ruivo Pinheiro, Réu, ao ser interrogado, disse que estava lá e

adquiriu os entorpecentes, mas o vendedor, ao ver a viatura, fugiu, o que também fez o Acusado, que dispensou as drogas, destinadas ao seu uso. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a desclassificação é medida que se impõe. Com efeito, os guardas estavam em patrulhamento e se depararam com o Réu, que, ao vê-los, dispensou um invólucro e empreendeu fuga, mas, após ser abordado, com ele houve a apreensão de dinheiro. Recuperado o invólucro, dentro dele havia 11 porções de "cocaína", com adesivo dos Simpson, e 02 porções de "maconha". Em que pese tais circunstâncias, houve apreensão de 11 porções de "cocaína", e 02 porções de "maconha", quantias pequenas e compatíveis com o uso. O testemunho dos guardas é seguro e coerente, todavia o Réu confessou que a droga apreendida lhe pertencia, porém aduziu que a tinha adquirido para seu uso. A quantia apreendida é pequena e compatível com a destinação pessoal, repito, e não foi presenciado pelos policiais qualquer ato de alienação. É estranho que o Réu estivesse em via pública às 20 h e 45 min, com dinheiro e drogas, da mesma forma que não se olvida a apreensão de outras cápsulas com os mesmos adesivos, mas tais circunstâncias são insuficientes para a condenação. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar DAVI RUIVO PINHEIRO, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. O Réu respondeu ao processo em liberdade, e, neste momento, ausentes motivos para a manutenção da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 25 de maio de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA